

0002633-40.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme esposado pela Ministra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002633-40.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002633-40.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2321714/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 21613537 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

7241/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2321714 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

7241/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYNÁ DIECINÉ SILVA TOME

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

KAYNÁ DIECINÉ SILVA TOME, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque em 25 de novembro de 2021, por volta de 22h15, na avenida

Paulista II, nº 364, Jd. Boa Vista, nesta cidade e comarca de Rio Claro, agindo em concurso e unidade de desígnios com Giam José Gomes Brandão dos Santos, teria exposto à venda, trazido consigo e guardado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 318 porções de cocaína, com massa líquida de aproximadamente 342,4g, e 61 porções de crack, produto da cocaína, com massa líquida de aproximadamente 19,9g.

Auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo de constatação (fls. 22/24) e exame químico-toxicológico (fls. 72/74).

A ré foi notificada (fls. 116 e 117), apresentou defesa prévia (fls. 121/125) e a denúncia foi recebida (fls. 133/136).

Foi proferida sentença com relação a Giam José (fls. 168/173). A ré Kainá não foi encontrada para ser citada, motivo pelo qual foi determinado o desmembramento do processo, prosseguindo-se com relação a ela nesses autos (fls. 168/173).

Posteriormente, compareceu aos autos, sendo pessoalmente citada (fls. 178).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. (SAJ)

A Defensoria Pública, por seu turno, pugnou pela absolvição da ré por nulidade da ação da guarda municipal. No mérito, requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio e apresentou teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, afasto a preliminar de nulidade processual decorrente da prisão em flagrante realizada pela guarda municipal.

Bem verdade que a atribuição principal da guarda municipal é a de realizar a guarda e conservação dos bens públicos. No entanto, qualquer um do povo pode realizar a prisão em flagrante, conforme determina o artigo 301 do Código de Processo Penal, sendo essa permissão extensiva aos membros da guarda municipal.

Assim, a prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, ainda que não seja inserida no rol das suas atribuições constitucionais descritas no artigo 144, § 8º, da CF/88, constitui ato legal, em proteção à segurança social.

Nesse sentido já se decidiu:

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova, porquanto a prisão foi efetuada por integrantes da guarda civil municipal. No mérito, pede absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede: (i) desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 no patamar máximo; (iii) fixação de regime inicial diverso do fechado; e (iv) questiona a proporcionalidade da pena de multa. Não há que se falar em nulidade. Havendo o estado de flagrância, qualquer um do povo pode realizar a prisão em flagrante, conforme determina o artigo 301 do Código de Processo Penal. No mérito, autoria e materialidade comprovadas, sendo que não poderia haver outro desfecho que

não a condenação. Não se há falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, posto que a condição de ser usuário não o impede de cometer o tráfico; aliás, situação comum é a de dependentes aderirem à espúria conduta como forma de satisfazer seus vícios. Pena não merece reparos. Regime fechado mantido. Pena de multa devidamente prevista pelo legislador, não havendo qualquer inconstitucionalidade - Recurso não provido." (TJSP, Apelação nº 0000873-87.2016.8.26.0309, Relator: Carlos Monnerat, Jundiaí, 8ª Câmara de Direito Criminal, D.J. 24/11/2016)

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo de constatação (fls. 22/24) e exame químico-toxicológico (fls. 72/74).

A autoria foi demonstrada a contento.

Perante a autoridade policial, a ré Kayná declarou que no dia 25 de novembro de 2021, às 22:15 horas, se encontrava comercializando entorpecentes com seu amigo Giam José Gomes Brandão dos Santos na Avenida Paulista II, altura do número 364, no bairro Jardim Boa Vista, quando notaram que uma viatura da Guarda Civil se aproximava e ficaram assustados. Dispensou uma sacola plástica na via pública com entorpecentes e dinheiro, a qual caiu próximo de seus pés. Foram abordados pelos guardas civis que se identificaram como Cesar e Tomazella, e estes pegaram a sacola plástica que dispensou, tendo localizado em seu interior 225 porções de cocaína embaladas em pedaços plásticos e R\$ 49,15, em cédulas e moedas de diversos valores. Segurava consigo um celular da marca Motorola, de sua propriedade. Narrou que os guardas civis revistaram Giam e localizaram sob a cueca que ele vestia um pedaço de plástico, no qual encontraram 93 micro tubos contendo cocaína e 61 pedras de crack, embaladas em pedaços plásticos. Confessou que vendiam os entorpecentes no local onde foram abordados, onde "funciona o ponto que sempre vende drogas com Giam", bem como que o dinheiro localizado na sacola é oriundo das referidas vendas. É usuária de cocaína. (fls. 05)

Não foi localizada para seu interrogatório em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia. (fls. 198)

A testemunha comum Antonio Marcelo Tomazella, guarda municipal, declarou que na data dos fatos fazia ronda quando viram que a ré e seu parceiro estavam juntos e ficaram assustados ao perceberem que seriam abordados. Relatou que a mulher dispensou uma sacola plástica na via pública, a qual caiu bem próxima de seus pés, e os abordaram. Localizaram no interior da sacola plástica dispensada por Kayná, porções de cocaína e crack em quantidade que não se recorda e certa quantia em dinheiro. Ao revistarem Giam, localizaram sob a cueca que ele vestia mais porções de crack e cocaína em quantidade que não se recorda. Eles teriam confessado a prática do tráfico de drogas. Não os conhecia até então. Disse que as drogas encontradas com Giam eram semelhantes àquelas encontradas com Kainá. (SAJ)

De igual forma discorreu a testemunha comum, Nilton César Larios, guarda municipal. Acrescentou que foram encontradas com o Giam 93 porções de cocaína e 61 pedras de crack e na bolsa dispensada por Kainá, 225 pacotes de cocaína e a quantia de R\$ 49,00. Também não conhecia os réus até então. (SAJ)

Analisando-se o conjunto probatório, reputo que a ré praticou o delito de tráfico de drogas.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos

testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente a ré, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

As provas coligidas aos autos dão conta do envolvimento da ré com o tráfico, pois os relatos dos guardas municipais são seguros nesse sentido, tudo estando a revelar que estava envolvida com a prática da mercancia ilícita de drogas e não se vislumbra que os guardas tivessem inventado isso apenas para prejudicar inocente.

Verifica-se que os guardas municipais foram firmes e uníssonos ao confirmarem a participação da ré na empreitada criminosa.

Em seus depoimentos prestados em juízo, os guardas afirmaram que faziam patrulhamento no local dos fatos quando visualizaram a ré e seu parceiro assustados ao notarem a aproximação da viatura. A ré então dispensou uma sacola plástica na via pública, sendo encontradas no interior dessa sacola porções de cocaína e crack e certa quantia em dinheiro. Ao revistarem Giam, localizaram sob a cueca dele mais porções de crack e cocaína. A ré e seu parceiro confessaram informalmente a prática do tráfico de drogas.

Como se não bastasse, apesar de não ter comparecido em Juízo para apresentar sua versão sobre os fatos, quando ouvida na fase inquisitiva, a ré confessou a prática

do crime. Disse que estava comercializando entorpecentes na companhia de Giam, quando uma viatura a guarda civil se aproximou. Esclareceu ter dispensado uma sacola plástica na via pública com os entorpecentes e dinheiro, que foi posteriormente localizada pelos guardas, sendo encontrados em seu interior 225 porções de cocaína embaladas em pedaços plásticos e R\$ 49,15, em cédulas e moedas de diversos valores.

A ré também narrou que os guardas civis revistaram Giam e localizaram em poder dele 93 micro tubos contendo cocaína e 61 pedras de crack, embaladas em pedaços plásticos.

Desse modo, as circunstâncias envolvendo a abordagem da ré e de seu comparsa, o arremesso da sacola contendo numerosas porções de drogas e dinheiro pela ré, o encontro de grande quantidade de drogas em poder de Giam, bem como as confissões realizadas por ambos na fase inquisitiva revelam que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à mercancia ilícita, ainda mais quando a apreensão ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas, restando afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização da ré pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes é medida de rigor.

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base da ré no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais hábeis a majorá-la. Assim, sua pena inicial será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixo de diminuir a pena por já estar no seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observo a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A ré é primária, possui bons antecedentes e não há notícias nos autos de que se dedica a atividades criminosas ou integra organizações criminosas. Destarte, de rigor a redução da pena na metade, tendo em vista a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, de maneira que passará a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada "tráfico privilegiado", traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, "caput" e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam

equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”.

Embora o referido julgamento proferido pelo Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS – Tema 600, cancelando o enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016)

Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP:

“Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.” (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016)

Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta.

No presente caso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a

Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito de sua situação financeira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra KAYNÁ DIECINÉ SILVA TOME para condená-la às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e a prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo, a ser revertida para entidade de caráter social.

A ré terá o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

P. I.

Rio Claro, 07 de outubro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA